



Título: Artigo sobre Creative Commons

Autor(es): Paula Tecles e Leonardo Poli

CREATIVE COMMONS E DIREITOS AUTORAIS: uma nova perspectiva jurídica para um mundo tecnológico

CREATIVE COMMONS E DIRITTI D'AUTORE: una nuova prospettiva giuridica per un mondo tecnologico

Leonardo Macedo Poli*

Paula Maria Tecles Lara**

RESUMO: A nova realidade social que se apresenta demanda do Direito respostas imediatas para questões antes nunca imaginadas. O Direito, portanto, busca se adequar às novas demandas e evoluir junto com a sociedade, caracterizada pela intensa circulação da informação. Nesse contexto contemporâneo de inovação tecnológica e de alterações nas relações jurídicas analisa-se as licenças *Creative Commons* como instrumento de viabilidade dos direitos autorais em sede digital. Defende-se a idéia de que essas licenças complementam os direitos autorais, ou seja, elas são um verdadeiro mecanismo de efetivação da Lei 9610/98 na *internet*, uma vez que ambos buscam incentivar a criatividade e a produção de conhecimento, promovendo maior desenvolvimento social.

* Advogado, Mestre em Direito Processual pela PUC Minas, Doutor em Direito Civil pela UFMG, Professor da UFMG e da FUMEC, Professor e Coordenador do Programa de Pós-graduação da PUC Minas

** Advogada, Mestranda em Direito Privado pela PUC Minas.

PALAVRAS-CHAVES: Direito Autoral; *Creative Commons*; *Internet*.

RIASSUNTO: La nuova realtà sociale che se presenta domanda del Diritto risposte immediate a domande mai immaginata prima. La legge, dunque, cerca di adattarsi alle nuove esigenze ed evolvere insieme alla società, caratterizzata da intenso flusso di informazioni. Nel contesto contemporaneo di innovazione tecnologica e cambiamenti di rapporti giuridici si analizza le licenze *Creative Commons* come strumento di redditività del diritto d'autore in base digitale. Si difende l'idea che questi permessi sono complementare al diritto d'autore, voglio dire, essi sono un vero meccanismo di realizzazione della legge 9610/98 su *internet*, in quanto entrambe mirano a incoraggiare la produzione di creatività e conoscenza, per promuovere un maggiore sviluppo sociale.

PAROLE CHIAVE: Direito D'autore; *Creative Commons*; *Internet*.

1. INTRODUÇÃO

As pessoas utilizam seus computadores, *laptops*, *netbooks*, celulares, *ipads*, etc, para acessar obras intelectuais, sites de notícias, blogs preferidos, *e-mails* e consideram tal atitude lícita, já que se trata de um hábito rotineiro o acesso à *internet*.

Isso porque a sociedade contemporânea atribui legitimidade às novas tecnologias como fonte de desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico, através de uma maior acessibilidade à informação, à cultura e ao conhecimento.

No entanto, aos olhos da Lei 9610/98, atual lei de direitos autorais, muitos desses comportamentos poderiam ser considerados ilícitos, à luz de seu art. 46¹, que, segundo alguns

¹ Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução;

autores, possuiria um caráter taxativo (BITTAR, 2008, p.70), já que não se enquadrariam nas hipóteses de uso livre, nem mesmo naquelas previstas no art. 8º² da mesma lei, que trata das obras não protegidas pelo direito de autor, deixando de legitimar uma série de outras situações comuns hodiernamente, em sua maioria derivadas de fenômenos tecnológicos, tais como as acima citadas. Muitos juristas vem se posicionando de forma contrária a essa interpretação clássica, como se pode verificar a seguir:

“muitas dessas condutas, embora sejam, sob a leitura rigorosa da lei, violadoras de direitos autorais, na verdade, estão a serviço da liberdade de expressão³ e do

-
- a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;
 - b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
 - c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
 - d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
 - II - a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
 - III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
 - IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
 - V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
 - VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
 - VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
 - VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

² Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

- I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI - os nomes e títulos isolados;
- VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

acesso à cultura⁴, ou seja, de princípios constitucionalmente protegidos.”(BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 06).

Também neste sentido se posicionam outros juristas:

“o ordenamento jurídico foi surpreendido com a dinâmica estimulada pelas novas tecnologias, cuja capacidade de gerar fatos novos imobiliza o legislador, incapaz de acompanhá-la.” (WACHOWICZ, 2007, p. 71).

Assim sendo, o processo legislativo não consegue acompanhar a velocidade impressa às alterações das relações sociais, gerando um descompasso entre o ordenamento jurídico e as demandas da sociedade.

Nesse sentido, outros mecanismos de controle surgirão para regular as novas relações jurídicas. George Ripert, citado por Cristiano Chaves, afirma que, *“quando o Direito ignora a realidade, ela se vinga, ignorando o Direito.”* (FARIA, 2010, P. 322).

Nesse contexto de necessidade de controle jurídico não ofertado pelo ordenamento jurídico, surgem, como padrão de licenciamento, as licenças *Creative Commons*, semelhantes às licenças de *software* livre⁵, gerenciadas sem fins lucrativos.

Falar sobre *Creative Commons* não é tarefa das mais fáceis. Trata-se de assunto ainda pouco explorado, principalmente porque muitos pensam que o tema diverge e até desrespeita o próprio conceito de Direito Autoral.

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

⁴ Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

⁵ Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições. Definição trazida pela Wikipédia no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre, acesso em 16/04/2011.

Hildebrando Pontes, um dos críticos do movimento CC⁶, relata que “*aumenta a perplexidade quando se vê que as licenças Creative Commons definem conceitos jurídicos que não se coadunam com os princípios já consagrados pelo direito autoral.*”(PONTES, 2009, p. 120). E acrescenta que:

“Diante das dificuldades do controle da utilização das obras no espaço digital, os seguidores do movimento Creative Commons pretendem tornar irrestrita a circulação das obras, transformá-las em meros conteúdos virtuais, flexibilizar os conceitos autorais consolidados, políticas consideradas essenciais para o desenvolvimento do processo de formação cultural do país.” (PONTES. 2009, p. 137)

Nesse contexto de debates sobre a real função do *Creative Commons*, deve-se analisar seu caráter complementar aos direitos autorais e a sua importância jurídica para o mundo contemporâneo, ou seja, a necessidade de uma padronização de licenciamento para regular as relações entre criador de uma obra intelectual e a coletividade, frente a uma nova realidade tecnológica.

Essa recente alteração da dinâmica mundial estabelecida pela *internet*, permeada pelo constante avanço tecnológico, torna possível um maior acesso de todos à informação e, conseqüentemente, provoca uma modificação no desenvolvimento cultural de um povo, à medida que fornece maior acesso ao conhecimento a um maior número de pessoas.

A popularização do conhecimento é um fenômeno socialmente importante e o CC surgiu como forma de organizar e viabilizar o processo de sua distribuição sem, contudo, desrespeitar os direitos autorais. Assim, temos o CC como instrumento que proporciona uma efetiva proteção autoral para aqueles que utilizam a *internet* com o intuito de publicar, distribuir e comercializar suas obras.

⁶ A sigla CC será utilizada como abreviação do termo *Creative Commons*.

Através da adoção das licenças CC, torna-se possível a conjugação de uma ampla distribuição do conhecimento com a exploração comercial da obra, ou seja, temos uma união entre a liberdade de acesso e a geração de receitas para o autor.

Para se entender melhor o CC como forma de instrumentalização dos direitos autorais, será feita uma retrospectiva a fim de perceber em qual momento histórico-político os direitos autorais nasceram, com quais finalidades e para atender a qual demanda, pois, assim, perceberemos que o Direito está em constante evolução, adequando-se às transformações sociais.

Será importante analisar também a realidade mundial que culminou na criação do CC, ou seja, quais as alterações sofridas pela sociedade que geraram essa necessidade da padronização de licenças.

Além disso, conceituar-se-á o termo “*Creative Commons*” e examinar-se-á sua natureza jurídica essencialmente contratual, que tem como objetivo auxiliar os direitos autorais na regulamentação das relações jurídicas autorais estabelecidas na *internet*.

No entanto, esse não é seu objetivo principal, pois o CC incentiva primordialmente a criação de obras intelectuais colaborativas, ou seja, fundamenta a criação que é composta pela colaboração de vários autores, como, por exemplo, o ocorrido com a banda *White Stripes*, formada por um guitarrista (vocalista) e uma baterista. Eles se surpreenderam com a atitude de um baixista, que pediu autorização para inserir o som do baixo nas músicas de um recém lançado CD dos *Whites Stripes*; estes acharam a idéia interessante e aprovaram o resultado final, gerando uma obra em colaboração belíssima.

Dessa forma, pode-se considerar o CC como instrumento de viabilidade jurídica dos direitos autorais na *internet*, já que eles necessitam de um mecanismo de aplicação no ciberespaço, uma vez que seus institutos foram pensados em outro paradigma jurídico e social.

Ao final, concluir-se-á pelo fim das divergências e conflitos entre o CC e os direitos autorais, em face ao caráter complementar existente entre eles, já que a criação e implementação do CC têm como objetivo auxiliar os direitos autorais na regulamentação das relações jurídicas estabelecidas na *internet*, tendo como finalidade única o fomento à inovação e desenvolvimento social ao alcance de todos.

2. DIREITOS AUTORAIS E A CONTEMPORANEIDADE

Um panorama histórico é essencial para que possamos compreender os direitos autorais no mundo contemporâneo. O antecedente mais remoto desses direitos surge a partir da invenção da imprensa em 1455, por Gutenberg. Tal invento explicitou uma preocupação não com a tutela da obra em si, mas com a proteção dos investimentos advindos da criação intelectual.

Segundo Branco Júnior:

“A invenção da tipografia e da imprensa, no século XV, revolucionou os direitos autorais porque os autores passaram a ter suas obras tornadas disponíveis de maneira muito mais ampla. Nessa época, surgem os privilégios concedidos aos livreiros e editores, verdadeiros monopólios, sem que se visasse, entretanto, a proteger os direitos dos autores.”(BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 20)

ASCENSÃO relata que, *“a tutela do autor só surge com o Estatuto da rainha Ana, na Grã-Bretanha, em 1710. Então, o autor, apodera-se do privilégio da indústria”* (ASCENSÃO, 2007, p. 04), sendo *“a primeira norma legal que reconheceu o direito subjetivo do autor sobre sua obra, tendo-o feito como direito de propriedade.”* (POLI, 2008, p. 04). Na verdade, o objeto dessa proteção nada mais é do que a materialidade do exemplar e seu direito exclusivo de reprodução. Essa é a idéia chave do *copyright*⁷.

⁷ “O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema anglo-americano do direito autoral porque “[o] *common law* manteve-se dentro da visão dos privilégios de impressão; não foi basicamente afectado pela Revolução Francesa. Isso conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A base do direito era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a da reprodução (*copyright*). O *copyright* assenta assim principalmente na realização de cópias, de maneira que a utilidade económica da cópia passa a ser mais relevante que a criatividade da obra a ser copiada”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito do Autor e Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias. Revista de Direito Autoral – Ano I – Número I, agosto de 2004. Rio de Janeiro: Lumen Juris. *Apud* BRANCO JÚNIOR; LEMOS, 2005, p. 02)

Esse Estatuto inaugurou uma fase repleta de iniciativas de lei que visavam proteger os autores, incentivando sua produção intelectual e reforçando a idéia de hegemonia dos Estados, numa disputa de inovações culturais, tecnológicas e científicas.

Nesse contexto, em 1886, ocorreu em Berna na Suíça, uma conferência sobre direitos autorais, que resultou na elaboração da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas, que previu, entre outras normas, o direito de paternidade da obra e o direito de participação do autor nos lucros da eventual revenda de sua obra.

Encontramos também neste tratado, que serviu de base para a elaboração das leis de direitos autorais em todo mundo, inclusive no Brasil, a definição do que é obra literária, artística ou científica⁸, bem como a previsão em seu art. 9º⁹ do direito do autor de permitir a reprodução de suas obras de qualquer modo ou sob qualquer forma.

Desse modo, os direitos autorais nascem em decorrência de movimento que objetivava garantir e proteger os investimentos e lucros dos editores (atravessadores) levando os autores a reagir diante dessa desigualdade, uma vez que recebiam quantias irrisórias pela vendas de seus trabalhos aos livreiros, que ficavam com todo o lucro da comercialização da obra.

O importante aqui é perceber que as leis elaboradas nesse contexto de monopólio dos meios de distribuição do conhecimento não são as mais adequadas para aplicação na realidade

⁸ Artigo 2, nº 1: Os termos "obras literárias e artísticas" abrangem todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências.

⁹ Artigo 9, nº 1: Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.

atual, uma vez que o advento da *internet* socializou os meios de distribuição de conteúdo, proporcionando seu acesso a todos os interessados.

É inviável pensar em aplicar nossas leis autorais no ciberespaço, sem imaginar um mecanismo que adapte e instrumentalize a lei a essa nova dinâmica distributiva. O direito autoral, pensado como sendo um direito individual, “*inspirado por noções de defesa do homem enquanto criador*” (BITTAR, 2008, p. 08), influenciado pela doutrina liberal de supervalorização do indivíduo, não se coaduna com a atual realidade social, uma vez que vivemos em um Estado Democrático de Direito.

Ronaldo Lemos e Sérgio Vieira Branco Júnior, citando Marcelo Thompson Melo Guimarães, relatam:

“É de se ver que o princípio democrático demanda que o Estado compreenda a exata medida em que diversos preceitos aparentemente contrapostos nas leis e na própria Constituição se entrelaçam na síntese daquele que é o exato momento histórico experimentado pela sociedade.” (GUIMARÃES, 2005, p. 10).

A trajetória dos direitos autorais no Brasil iniciou-se em 1827, com a lei de criação das Faculdades de Direito de Olinda e São Paulo, que estabelecia em seu art. 7º o seguinte:

Os Lentes farão a escolha dos compêndios da sua profissão, ou os arranjarão, não existindo já feitos, com tanto que as doutrinas estejam de acordo com o sistema jurado pela nação, estes compêndios, depois de aprovados pela Congregação, servirão interinamente; submetendo-se porém a aprovação da Assembléia Geral, e o governo fará imprimir e fornecer às escolas, competindo aos seus autores o privilegio exclusivo da obra por dez anos.

O Código Criminal do Império de 1830 instituiu penas para quem reproduzisse sem autorização obras de autores brasileiros vivos ou antes de completados 10 anos de sua morte, caso tivessem herdeiros.

Segundo Denis Borges Barbosa, “*apenas na Carta Republicana de 1891 subiu a matéria ao nível constitucional. Em 1898, a Lei 496, chamada Lei Medeiros de Albuquerque, elaborou pela primeira vez um tratamento mais abrangente.*” (BARBOSA, 2010, p. 33)

O Código Civil de 1916 continha previsão que assegurava direitos do autor, reservando inclusive um capítulo à propriedade intelectual em suas várias manifestações. Somente em 1973 os Direitos Autorais foram regulamentados pela Lei 5.988.

Atualmente os direitos autorais estão previstos na lei 9.610/98, que dentre outras coisas, ampliou o prazo de proteção aos direitos autorais para 70 anos após a morte do autor e manteve como facultativo o registro para proteção das obras intelectuais. Assim,

“apesar do desenvolvimento tecnológico que fez surgir, por exemplo, a tecnologia digital e a internet, as principais instituições do direito de propriedade intelectual, forjadas no século XIX com base em uma realidade social completamente distinta da que hoje presenciamos, permanecem praticamente inalteradas.”(LEMOS, p.08, 2005)

Diante desse quadro, o princípio da funcionalidade do direito subjetivo autoral¹⁰ servirá de base para uma nova interpretação do Direito Autoral contemporâneo, ou seja, por esse princípio, a autonomia individual do autor sobre sua obra não pode ser absoluta, uma vez que *“interessa à sociedade a tutela de suas conseqüências sociais, econômicas, políticas e normativas”* (POLI, 2008, p. 154)

Apesar disso, nossa lei autoral não consegue abarcar todas as hipóteses nas quais incidem direitos autorais, ainda mais numa sociedade informatizada. Diante dessa nova realidade *“faz-se necessária uma releitura conceitual das instituições de Direito Autoral no sentido de acompanhar a nova realidade tecnológica.”* (POLI, 2008, p. 143)

Desse modo, torna-se imperioso o implemento de mecanismos que auxiliem a legislação autoral a se adaptar às novas contingências sociais, de forma que a lei possa atingir seu real fim, regular as condutas humanas, preservando o equilíbrio social.

¹⁰ Segundo Leonardo Poli direito subjetivo autoral refere-se “ às faculdades ou liberdades juridicamente reconhecidas ao autor sobre sua criação”. (POLI, 2008, p. 02)

3. CREATIVE COMMONS E A REALIDADE SOCIAL

A sociedade contemporânea é caracterizada, primordialmente, pela revolução tecnológica. Hoje vivemos em constante busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento, pois a tecnologia evolui de maneira apressada e quase não conseguimos acompanhá-la, quiçá o Direito.

De fato, a realidade social e jurídica sofreu, sofre e sofrerá impactos perenes em razão do advento da *internet*, que é uma das principais representantes do avanço alcançado pelo homem na busca por uma efetiva comunicação e comercialização entre os povos.

A criatura superou as expectativas do criador, pois a *internet* não só unificou os meios de comunicação, mas também suprimiu as fronteiras nacionais, integrando todo o planeta em uma só rede.

Dessa integração tecnológica mundial surgem relações jurídicas que não podem ficar à margem do Direito. Ronaldo Lemos nos diz:

“Se a propriedade intelectual forjada no século XIX passa a apresentar sérios problemas de eficácia quando se depara com a evolução tecnológica, não cumpre apenas ao jurista apegar-se de modo ainda mais ferrenho aos seus institutos como forma de resolver o problema, coisa que a análise jurídica tradicional parece querer fazer. Cumpre, sim, ver as alterações que a idéia de propriedade intelectual sofre ou poderia sofrer em razão dessas transformações, enfrentando essas questões de maneira aprofundada, sob pena de se ignorar uma parcela muito grande da realidade.”(LE MOS, 2005, p. 13)

Quando o Direito não propõe soluções adequadas, a sociedade busca se adaptar a essa revolução da informação, criando alternativas mais convenientes.

Boaventura de Souza Santos, citado por Sérgio Silveira, esclarece o assunto dizendo que *“é por meio da imaginação que os cidadãos são disciplinados e controlados pelos Estados, mercados e outros interesses dominantes, mas é também da imaginação que os cidadãos desenvolvem sistemas coletivos de dissidência e novos grafismos da vida coletiva.”*(2005, p. 437).

Um exemplo de sistema coletivo de dissidência, do qual falava Boaventura de Souza Santos, é o *software* livre, criado com o intuito revolucionário de gerar uma obra em colaboração, tendo na *internet* sua mola propulsora.

Sérgio Amadeu esclarece como foi criado o *software* livre, que é a raiz inspiradora do *Creative Commons*:

“Foi a partir da indignação ativa de um então integrante do MIT, Richard Stallman, contra a proibição de se acessar o código fonte de um software, certamente desenvolvido a partir do conhecimento acumulado de tantos outros programadores, que em 1985 foi criada a Free Software Foundation. O movimento de software livre começou pequeno. Reunia e distribuía programas, ferramentas livres, com o código-fonte aberto. Assim, todas as pessoas poderiam ter acesso não só aos programas mas também aos códigos em que foram escritos. A idéia era produzir um sistema operacional livre, que tivesse a lógica do sistema Unix de que era proprietário, ou seja, pertencente a uma empresa. Por isso, os vários esforços de programação eram reunidos em torno do nome GNU (Gnu Is Not Unix).

Para evitar que os esforços do movimento fossem apropriados indevidamente e patenteados por algum empreendedor oportunista, novamente bloqueando o desenvolvimento compartilhado, a Free Software Foundation inventou a Licença Pública Geral, GPL em inglês, conhecida como copyleft, em contraposição ao copyright. Ela é a garantia de que os esforços coletivos não serão indevidamente considerados propriedade de alguém. O GPL é aplicável em todas as frentes em que os direitos autorais são utilizados: livros, imagens, músicas e softwares.

Com a difusão da Internet, o movimento de software livre ganhou o mundo e logrou produzir um sistema operacional livre, completo e multifuncional, o GNU/LINUX. Em 1992, o finlandês Linus Torvald conseguiu compilar todos os programas e ferramentas do movimento GNU em um kernel, um núcleo central, o que viabilizou o sistema operacional. Torvald denominou este seu esforço de Linux, ou seja, “Linus for Unix”.

O Gnu/Linux baseia-se nos esforços de mais de 400 mil desenvolvedores espalhados pelos cinco continentes e por mais de 90 países. Como bem apontou Moon e Sproull (1999), é extremamente difícil encontrar desenvolvimentos de engenharia comparáveis em extensão, envolvimento de pessoas e alcance geográfico como o empreendido pelo projeto do Gnu/Linux. A Microsoft, maior empresa de software do planeta, produz o sistema operacional windows e conta em seu quadro funcional com, aproximadamente, 30 mil funcionários, concentrados em sua sede em Seattle, EUA. Em breve, o desenvolvimento e a melhoria anual do GNU/Linux contará com um milhão de programadores. São estudantes, especialistas, amantes da computação, diletantes, gente à procura de fama, empresas em busca de lucro, profissionais de altíssimo nível, entre tantos outros. Dificilmente uma empresa privada terá condições de acompanhar o ritmo de inovações incrementais de uma rede tão variada e tão inteligente.” (SILVEIRA, p. 476/477, 2005)

Nota-se, então, que o criador do *software* livre não abre mão de todos os seus direitos autorais, pelo contrário, ele renuncia a alguns deles através do mecanismo da licença¹¹. Na verdade, o ato de licenciar em si seria considerado como exercício de um direito autoral, já que somente o criador do *software* (obra intelectual) poderia decidir em licenciar ou não sua criação.

Uma característica fundamental da licença jurídica do *software* livre é a cláusula de compartilhamento obrigatório, ou seja, o licenciado de hoje será o licenciante de amanhã, formando-se, assim, um licenciamento em rede que tem como produto uma obra intelectual em eterna criação.

Nesse contexto de colaboração, outros trabalhos foram desenvolvidos, sendo um deles o *Creative Commons*, que muito se baseou no *software* livre. Segundo Ronaldo Lemos

“existe hoje um imenso número de projetos colaborativos em todo o mundo, todos fundados em uma estrutura aberta como a do software livre, da qual qualquer interessado pode participar.”(LEMOS, 2005, p. 80)

O CC é um projeto sem fins lucrativos criado pelo professor Lawrence Lessig, da Universidade de Stanford, que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais, garantindo proteção e liberdade para artistas e autores.

Parte-se da idéia original dos direitos autorais “todos os direitos reservados”, adaptando-a para “alguns direitos reservados” e,

“tem por objetivo desenvolver licenças públicas, isto é, licenças jurídicas que possam ser utilizadas por qualquer indivíduo ou entidade, para que seus trabalhos sejam disponibilizados na forma de modelos abertos” (LEMOS, 2005, p. 82).

Com esse objetivo, Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, explica:

¹¹ Segundo Ascensão: “... não há motivo para admitir um *numerus clausus* das licenças. As partes podem dar as autorizações que entenderem. A conclusão é facilitada, porém, por estas figuras terem natureza obrigacional.”(ASCENSÃO, 2007, p. 309).

“Em outras palavras, o Creative Commons cria instrumentos jurídicos para que um autor, um criador ou uma entidade diga de modo claro e preciso, para as pessoas em geral, que uma determinada obra intelectual sua é livre para distribuição, cópia e utilização. Essas licenças criam uma alternativa ao direito da propriedade intelectual tradicional, fundada de baixo para cima, isto é, em vez de criadas por lei, elas se fundamentam no exercício das prerrogativas que cada indivíduo tem, como autor, de permitir o acesso às suas obras e a seus trabalhos, autorizando que outros possam utilizá-los e criar sobre eles.” (LEMOS, 2005, p. 83).

A idéia de “commons” nos remete àquilo que é público, tais como parques, rios, mares, praças, obras intelectuais que já estejam em domínio público, etc. Estas últimas diferem-se das demais pelo fato de serem consideradas obras não rivais, ou seja, seu uso não se esgota, possibilitando inclusive que uma multidão de pessoas as utilizem simultaneamente, sem que se forme um caos.

A tecnologia da informação potencializou essa característica, uma vez que possibilitou a milhares de pessoas o acesso ao conteúdo digital via *internet*. Um batalhão ao redor do mundo, simultaneamente, pode acessar textos, fotos, músicas, livros, vídeos e muito mais conteúdo pela *internet*.

É o advento da *internet* que maximiza o poder de distribuição do conhecimento, além de proporcionar um meio para a geração de obras colaborativas, ou seja, obras que são construídas pelo intelecto de várias pessoas, tal qual ocorre com o *software* livre e com a enciclopédia digital *Wikipédia*, que facilitou o acesso à cultura e informação através do interesse de muitos em construir uma enciclopédia participativa, em que todos contribuem para sua formação.

A licença CC surge com esse mesmo objetivo, adequar as necessidades sociais aos novos meios de comunicação, criando soluções jurídicas para que autores possam decidir como exercerão seus direitos e faculdades, já que para alguns criadores, muito mais importante do que vender suas obras é ter seu nome reconhecido, divulgar sua obra e conseguir dar continuidade ao seu trabalho.

Esses autores utilizam a maneira mais acessível para atingir esse objetivo, qual seja, a *internet*. Dessa maneira, podemos dizer que a licença CC é um contrato estabelecido entre autor da obra digital a ser licenciada e a coletividade, aqui entendida como a sociedade ou todo aquele interessado na obra licenciada.

Nesse sentido:

“Juridicamente, as licenças públicas se classificam como contratos atípicos, cuja celebração é autorizada por nosso Código Civil, nos termos de seu art. 42542. Podem ser classificadas também como contratos unilaterais, já que geram direitos e obrigações para somente uma das partes.” (LEMOS; BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 20)

As licenças CC variam de acordo com as necessidades do licenciante, que pode escolher entre os diversos padrões já estabelecidos aquela que se adapta melhor aos seus anseios. Além disso, tais licenças estão presentes em mais de 40 países do mundo e também são completamente compatíveis com o direito brasileiro. Ronaldo Lemos nos mostra que:

“Essas licenças são escritas em três níveis sob o projeto Creative Commons: um nível para leigos, passível de entendimento por quem não tem formação jurídica, explicando no que consiste a licença e quais os direitos que o autor está concedendo; um nível para advogados, em que a redação da licença se utiliza de termos jurídicos, tornando-a válida perante um determinado ordenamento jurídico; e um nível técnico, em que a licença é transcrita em linguagem de computador, permitindo que as obras sob ela autorizadas no formato digital sejam digitalmente “marcadas” com os termos da licença, e permitindo que um computador identifique os termos de utilização para os quais uma determinada obra foi autorizada. Esta última modalidade é particularmente importante em face da crescente regulação arquitetônica da internet, e pode permitir no futuro que, mesmo na eventualidade do fechamento completo da rede, os trabalhos licenciados sob um tipo de licença como esta do Creative Commons possam continuar a ser interpretados como livres por um determinado computador.” (LEMOS, 2005, p. 84)

Importante ressaltar que essa adequação trazida pelo CC não vem do poder estatal e não provoca nenhuma alteração legislativa, servindo apenas como instrumento de viabilidade dos direitos autorais originalmente previstos em nossa legislação, pois essas licenças só se efetivam porque temos direitos autorais previstos e protegidos em nosso ordenamento.

Com a adoção do CC conseguimos conjugar a proteção autoral com a preocupação sempre presente quanto ao acesso de conteúdo informativo por todos. De acordo com Lemos “a

idéia é permitir a criação de uma coletividade de obras culturais publicamente acessíveis, incrementando o domínio público e concretizando as promessas da internet e da tecnologia de maximizar o potencial criativo humano.”(2005, p. 84)

Não há como negar as mudanças sociais trazidas pela *internet*, que possui como alma a interação comunicativa. É nesse espaço interativo que o direito autoral tradicional torna-se obsoleto, necessitando de mecanismo que o adaptem à nova conjuntura digital:

“O Direito Autoral clássico não foi elaborado para a tecnologia digital. Seus institutos e conceitos não se encaixam na tecnologia digital, o que leva comumente à aplicação de analogias que muitas vezes não são satisfatórias. Por exemplo, a simples fixação da obra em suporte digital tem sido considerada como ato de reprodução da obra, o que não é. Da mesma forma, sua disponibilização em rede digital tem sido considerada como forma de comunicação pública da obra, o que também não é.” (POLI, 2008, p. 135-136)

O *software* livre, bem como as licenças CC são instrumentos poderosos de modificação social e promoção de desenvolvimento, através do uso de seu espaço colaborativo que multiplica as formas de disseminar conhecimento e democratizam seu uso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, não resta dúvidas que a rede mundial de computadores alterou de forma significativa a forma de acesso à cultura. A informação está ao alcance de todos.

As intenções e objetivos dos autores de hoje são muito diferentes daqueles que existiam à época do surgimento dos direitos autorais, demonstrando que é necessária uma reinterpretação da Lei para que ela se adapte melhor às demandas sociais.

Não podemos ignorar que a *internet* revolucionou inclusive a forma de se pensar e agir. Ela se transformou em verdadeiro instrumento de distribuição de conhecimento, uma vez que disponibiliza conteúdos provenientes de diversos países, promovendo uma interação mundial.

Mas o Direito Autoral ainda continua arraigado aos conceitos tradicionais e principalmente à idéia individualista de direito subjetivo do autor, sem conseguir perceber a importância e o impacto da obra intelectual no desenvolvimento cultural de uma sociedade, ou seja, as normas jurídicas não podem ser engessadas e o Direito não pode ser cristalizado sob o argumento de defesa das instituições jurídicas clássicas, pois estas também sofrem constantes modificações, buscando sempre um aprimoramento para melhor corresponder aos anseios da sociedade. A sociedade anseia pela funcionalização do direito autoral.

Nessa conjuntura, além de buscar proteger as criações do espírito humano, o Direito de Autor deve buscar também se adaptar às novas demandas sociais, utilizando-se de instrumentos como o CC, que facilita a aplicação dos direitos autorais em sede digital.

O CC não pretende apenas tornar irrestrita a circulação das obras, seus objetivos são mais amplos, abrangendo o incentivo à criatividade, à difusão do conhecimento, à distribuição não onerosa das criações artísticas, dentre outros.

Dessa maneira não há conflito entre as licenças públicas e os direitos autorais tradicionais, já que ambos buscam atingir os mesmos objetivos, através de caminhos diversos.

Sem a sistematização dos direitos autorais não poderíamos conceber licenças que renunciassem a eles, ou seja, a licença só existe porque temos a proteção autoral. A existência das licenças públicas possuem sua base nos direitos autorais, o que não elimina a eficácia atribuída a estes, uma vez que cabe ao autor estipular quais direitos estará licenciando, renunciando, portanto. A autonomia privada não pode ser vista como fenômeno de imposição do exercício de direitos.

Dessa forma, o CC pode ser visto como instrumento de viabilidade jurídica dos direitos autorais na *internet*, uma vez que o *Creative Commons* facilita a aplicação dos direitos autorais no mundo virtual.

O Direito Autoral contemporâneo deve levar em conta a sua importância “como instrumento de satisfação do interesse social de desenvolvimento cultural e do interesse político de legitimação da ordem jurídica.” (POLI, 2008, p. 154)

REFERÊNCIAS:

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 754 p.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 1079 p.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 188 p.

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 257 p.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: _____. *Vademecum Compacto Saraiva*. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 07 - 112.

BRASIL. Lei n. 5988 de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109137/lei-5988-73> , Acesso em 17/01/2011.

BRASIL. Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. In: _____. *Vademecum Compacto Saraiva*. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1315-1333.

BRASIL. Lei n. 9610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. In: _____. *Vademecum Compacto Saraiva*. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1352-1361.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010. V. II, tomo I, 397 p.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. V. 1, p. 635-675.

COLTRO, Antônio Carlos Mathias. O Direito como Arte. In: LIMA, Taisa Maria Macena de; SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna (Coords.). *Direitos e Fundamentos entre Vida e Arte*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 23-38.

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 534 p.

FARIA, Roberta Elzy Simiqueli de. Autonomia da Vontade e Autonomia Privada: uma distinção necessária. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades II*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 55 - 71.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. *Curso de Direito Constitucional*. Rio de Janeiro, 2010. 1071 p.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975. 1499 p.

FIÚZA, César. Crise e Interpretação no Direito Civil da Escola da Exegese às Teorias da Argumentação. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – Atualidades*. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 23-59.

FIÚZA, César. *Direito Civil: curso completo*. 14 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 1123 p.

GALUPPO, Marcelo Campos. *Da Idéia à Defesa: monografias e teses jurídicas*. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 224 p.

GARCIA, Hamílcar de. *Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete*. Vol 1, 5ª ed. Rio de Janeiro: Delta, 1987. 1056 p.

LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. *Propriedade Intelectual: Uma abordagem pela análise econômica do Direito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 121 p.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, Tecnologia e Cultura*. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 211 p.

LEMOS, Ronaldo. Creative Commons, Mídia e as Transformações Recentes do Direito da Propriedade Intelectual. **Revista DireitoGV**, São Paulo, vol. 01, nº 01, p. 181 – 187, maio 2005.

LEMOS, Ronaldo; BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Copyleft, Software livre e Creative Commons: A nova feição do Direitos Autorais e as Obras Colaborativas*. Rio de Janeiro, 2006, 29 p.

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A autonomia privada e a função social da empresa. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades II*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 339 - 348.

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. *Manual da Monografia Jurídica: como se faz uma monografia, uma dissertação, uma tese*. São Paulo: Saraiva, 1997. 207 p.

POLI, Leonardo Macedo. A funcionalização do Direito Autoral: Limitações à Autonomia Privada do titular de Direitos Autorais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades II*. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 315 - 338.

POLI, Leonardo Macedo. Análise teórica e prática do monopólio de exploração econômica de obras intelectuais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). *Direito Civil – atualidades IV*. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 537 - 561.

POLI, Leonardo Macedo. *Direito Autoral: parte geral*. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 171 p.

PONTES, Hildebrando. *Os contratos de cessão de direitos autorais e as licenças virtuais creative commons*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 160 p.

ROBERTO, Giordano Bruno Soares. *Introdução à História do Direito Privado e da Codificação*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 110 p.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Inclusão Digital, Software Livre e Globalização Contra-hegemônica. **Revista Parcerias Estratégicas: Seminários temáticos para a 3ª Conferência Nacional de C,T&I**, Brasília, nº 20, p. 459 – 484, junho de 2005. Disponível em: <http://www6.ufrgs.br/soft-livre-edu/inclusao-digital-software-livre-e-globalizacao-contra-hegemonica-2/> . Acesso em: 15/04/2011.

SOUZA, Allan Rocha de. As etapas iniciais da proteção jurídica dos direitos autorais no Brasil. **Revista Justiça e História**. Porto Alegre, n. 11, v. 06, p. 136 – 186, 2006. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucha/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n11/index.html. Acesso em: 17/04/2011.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direitos de autor. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, nº 107, p. 54 – 68, jul/ago. 2010.

SUÍÇA, *Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas*. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_da_Uni%C3%A3o_de_Berna. Acesso em: 20/01/2011.

TORRES, Antonio Carlos Esteves et al (Org.). *Propriedade intelectual: plataforma para o desenvolvimento* / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Rio de Janeiro/ São Paulo/ Recife: Renovar, 2009. 217 p.